

1500206-14.2022.8.26.0019  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto Qualificado  
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR  
Comarca: Americana  
Foro: Foro de Americana  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 19/05/2022  
... (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Americana  
Foro de Americana  
2ª Vara Criminal  
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-14.2022.8.26.0019 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500206-14.2022.8.26.0019  
Classe - Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado  
Documento de Origem:  
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033921/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 22848764 - 04º D.P. AMERICANA, 278/22/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2033921 - 04º D.P. AMERICANA  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
FERNANDO ROCHA DOS SANTOS  
Réu Preso

Tramitação prioritária  
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

FERNANDO ROCHA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, mediante escalada, tentou subtrair, para si, 35 quilos de alumínio, avaliados em R\$600,00, pertencentes à empresa BRUNA ALVES SANTANA, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 111/113).

O réu foi citado (fls. 160), apresentando defesa (fls. 136/138).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa arroladas, bem como o réu foi interrogado (fls. 189/190).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 194/198), entendendo estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu pelo delito de furto qualificado tentado.

A Doutora Defensora do réu (fls. 203/208) requereu a absolvição, ou a desclassificação para furto simples, e a aplicação da atenuante da confissão.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 07/10 e 11/12, e laudo de fls. 173/178.  
A autoria é indubitosa.

O réu foi preso em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho “é a certeza visual do crime”. A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:  
“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, o réu estava na posse do bem subtraído. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, “De la Apreciación de las Pruebas”, tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, “La Prueba,

su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - (...) - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A vítima, ouvida em Juízo, informou que o alarme do estabelecimento comercial foi acionado, sendo que verificou pelo sistema de câmeras e dirigiu-se ao local. Disse, ainda, que encontrou o réu, com os objetos em cima da moto, e quando abordado, ele deixou os objetos e saiu correndo. Narrou que perseguiu o réu, e com a ajuda de outros conseguiram deter o réu, e acionaram a polícia. Declarou que o réu pegou um saco e uma caixa de alumínio e pulou o muro. Por fim, reconheceu o réu.

Não há nos autos prova de que a vítima conhecia o réu anteriormente ou que tivesse intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter o réu.

Os Policiais Militares, ouvidos em Juízo, esclareceram que foram informados de um possível furto em andamento em um estabelecimento de reciclagem. Declararam, ainda, que tomaram conhecimento de que a vítima, verificando a ação por meio de câmeras de segurança, dirigiu-se ao local, e o réu, o qual já tinha objetos em sua moto, correu e foi detido, com a ajuda de populares. Narraram que, quando chegaram, o réu já estava sob o domínio da vítima, e não visualizaram os populares. Indagado, o réu alegou ser usuário de drogas, tendo cometido o delito para a aquisição da substância entorpecente. Por fim, conduziram o réu ao hospital, e após a Delegacia.

Por fim, as testemunhas de defesa, Rivaildo e Itamar, nada relataram acerca dos fatos, apenas informaram as características pessoais e profissionais do réu, e confirmaram acerca do uso de drogas pelo acusado e tentativa da família acerca de tratamento em clínica.

O réu Fernando, ouvido em Juízo, confirmou a prática do furto, declarando que praticou o delito com intenção de aquisição de drogas. Confirmou, ainda, que

procedeu a escalada do muro para a obtenção dos objetos.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado, inclusive acerca da qualificadora (escalada), reforçada pelas testemunhas e pelo próprio réu, não sendo possível a desclassificação para o delito de furto simples.

Ainda, a qualificadora de escalada encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 173/178, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Verifica-se, também, que não há que falar-se em inimputabilidade em razão de consumo de substância entorpecente e/ou álcool. Primeiro, porque não comprovada. Segundo, porque a ingestão de bebida alcoólica, ou droga, só é excludente de culpabilidade se oriunda de fato culposo ou de força maior. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

DANO QUALIFICADO, DESACATO E LESÃO CORPORAL LEVE CIRCUNSTANCIADA, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE, COM REDUÇÃO DAS PENAS. Materialidade e autoria dos delitos bem demonstradas nos autos (...). SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL. Não há que se falar em inimputabilidade ou em semi-imputabilidade da apelante, pois tanto o artigo 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal, como os artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, exigem, para a isenção ou redução da pena, que a embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, e a dependência ou o efeito de droga, sejam provenientes de caso fortuito ou força maior, e que o agente, em razão da embriaguez, dependência ou efeito de drogas, seja, ao tempo da ação ou omissão, inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Já a embriaguez, voluntária ou culposa, como no presente caso, não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, inciso II). Adoção legislativa da actio libera

in causa, de modo que, se o agente deu causa à embriaguez voluntária (o agente quis se embriagar) ou culposamente (o agente não queria embriagar-se, mas por imprudência chega àquele estado), ele responde pelos atos praticados em estado de ebriedade. (...). (TJSP; Apelação Criminal 1500190-16.2019.8.26.0585; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de exame de dependência químico-toxicológica. Inocorrência. Ato justificadamente indeferido pelo magistrado no exercício de seu livre convencimento motivado - Mérito Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Condenação mantida. Pleito de isenção de pena, com encaminhamento a tratamento adequado à dependência química, nos termos do art. 45, da Lei n.º 11.343/06. Descabimento. Dispositivo legal que exige comprovação da inimputabilidade ou prática do delito sob efeito de drogas em razão de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos, não bastando a mera alegação de dependência química. (...). (TJSP; Apelação Criminal 0001976-42.2009.8.26.0288; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/10/2014; Data de Registro: 03/11/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Reconhecimento efetivado pela vítima e confissão parcial dos acusados que, aliados aos demais elementos de convicção, dão a certeza do cometimento do delito - Inimputabilidade que não restou comprovada - Eventual atuação delitiva sob efeito ou dependência de droga que não decorreu de caso fortuito ou força maior - Condenação mantida - (...). (TJSP; Apelação Criminal 0053723-90.2014.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)

Por fim, o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, qual seja, o de ter sido surpreendido pela vítima.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado pela prática de furto é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que uma delas (fls. 3/45) deve ser considerada na dosimetria da pena para a fixação da pena-base, como mau antecedente. A prática reiterada de crimes indica a má formação da personalidade, sempre voltada à prática de ilícitos criminais, antecedentes que impõem majoração da pena base como circunstância judicial. No mais, em se tratando de furto qualificado (escalda), há maior reprovabilidade da conduta do acusado. Exaspero, por isso, a pena base na 1/6 (um sexto), delimitando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O entendimento da doutrina é pela possibilidade de utilização de condenações distintas para avaliar maus antecedentes e para a agravante da reincidência: "Cumpra-se precisar que na hipótese de diversas condenações definitivas, uma valerá para majorar a pena-base, como maus antecedentes, e a outra para respaldar o aumento da reincidência, sem qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem." (Flávio Augusto Monteiro de Barros, "Técnica de Aplicação da Pena", ed. Oliveira Mendes - APAMAGIS - Associação Paulista de Magistrados, 1997, p.3).

Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

STJ, SÚMULA N. 241 - A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. 3. (...). 5. Habeas corpus concedido de ofício para redimensionar a pena, nos termos do voto. (HC 528.390/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020)

Na segunda fase, anoto que o réu é também reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 37/45. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ)

Tendo em vista que o delito se deu na forma tentada, diminuo a pena de 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido, que se aproximou sobremaneira da consumação, porquanto chegou a retirar objetos do local para a subtração, perfazendo assim um total de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Não é possível o reconhecimento do privilégio constante do § 2º, do artigo 155, do Código Penal em caso de furto qualificado. Além disso, para que o benefício fosse concedido, é requisito que o réu seja primário e portador de bons antecedentes. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. 2. No caso, um dos réus é reincidente e o valor da coisa subtraída, somado ao prejuízo suportado pela vítima para o conserto de sua residência em razão do arrombamento, não pode ser considerado pequeno para fins de reconhecimento do privilégio pleiteado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1511869/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

FURTO QUALIFICADO - Aplicação do privilégio - Impossibilidade:117 - É impossível a aplicação do privilégio ao furto qualificado, vez que o agente de tal delito representa maior soma de perigo para a sociedade, tanto que o Legislador Penal teve o cuidado de tratar do benefício antes das circunstâncias qualificadoras. RJDTCRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 220 RELATOR: - THYRSO SILVA

Ademais, os péssimos antecedentes do réu desaconselha a adoção de tal benefício.

À míngua de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu não poderá apelar em liberdade, por ser reincidente. Além disso, o réu encontra-se preso por força de prisão em flagrante delito, o que demonstra que sua custódia é necessária para a garantia da ordem pública.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal condenar o réu FERNANDO ROCHA DOS SANTOS à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 07 (sete) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal; bem como para condená-lo no pagamento das custas processuais, que fixo em 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.  
P. I. C.

Americana, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA